

1502740-17.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico em 18 de dezembro de 2021.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta da 1 hora, na Rua Pedra, altura do número 100, e na Rua Rio São Francisco, número 475, ambas nesta cidade, os denunciados transportavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502740-17.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502740-17.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344550/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22025043 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 6417/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2344550 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALEXSANDER DE SOUZA MARQUES e outro

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra LUCAS ALEKSANDER DE SOUZA MARQUES e SIDNEI PEREIRA GOMES, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico em 18 de

dezembro de 2021.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2021, por volta da 1 hora, na Rua Pedra, altura do número 100, e na Rua Rio São Francisco, número 475, ambas nesta cidade, os denunciados transportavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 7 (sete) tijolos de cocaína e 91 (noventa e um) tijolos, 1 (um) tablete e 101 (cento e um) invólucros de maconha.

Os denunciados foram devidamente notificados (págs. 188/189) e apresentaram defesa prévia (págs. 210/225 e 238/253).

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (págs. 274/275).

Durante a fase de instrução, ouviram-se as testemunhas David de Paula Cândido e Diego Roberto de Souza Pedro e, após, os acusados foram interrogados (págs. 310/312).

A testemunha David De Paula Cândido, policial militar, declarou que se encontrava em patrulhamento e o carro do acusado passou em contrafluxo e com odor de maconha. Fizeram a volta e realizaram a abordagem. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em posse dos acusados. Na busca veicular, encontraram um tijolo de maconha. Em razão disso, separaram os indivíduos e os entrevistaram individualmente. LUCAS informou que era apenas usuário e SIDNEI fornecia maconha para ele. Deslocaram-se até a residência do SIDNEI para pegar documentos porque o Distrito Policial costuma pedir a eles para levar documentação para não fazer legitimação. Quando chegaram na casa do SIDNEI, pela janela já puderam visualizar material para manusear drogas e para fracionar para venda, como balanças e potes de vidro com drogas dentro. Como ele estava em posse da chave, entraram no local e encontraram as drogas. Quando perguntado a SIDNEI, ele teria assumido a propriedade da droga, eximindo qualquer outra pessoa de responsabilidade. Ao ser questionado por esta magistrada, afirmou que, no veículo, encontraram um tijolo de maconha; a droga foi encontrada pelo outro policial que realizou a busca veicular, Diego. Quando encontraram a droga, não pediram apoio. Após interrogar informalmente LUCAS, pediram apoio. Apenas sua equipe foi até a casa de SIDNEI; a outra viatura de apoio permaneceu no local da abordagem. Não havia ninguém na casa. Entraram na casa com a chave de SIDNEI, o qual teria informado que sua mãe estava na casa. O Ministério Público não fez perguntas. Ao ser questionado pela Defesa, afirmou que os acusados faziam uso de maconha no interior do veículo. A revista pessoal foi realizada por seu parceiro, Diego. Não encontraram nada em busca pessoal. Não recorda se o celular estava na posse dos acusados ou no interior do veículo. Após encontrar as drogas, uma outra viatura chegou para apoiar a abordagem. A Delegacia exige documentos dos presos. SIDNEI permaneceu no local da abordagem. A casa fica a 3km de distância do local da abordagem. Há outras casas no mesmo quintal. Abaixo da casa de SIDNEI, havia outra residência. Na calçada, sentiram odor de maconha. As outras residências não foram averiguadas. É um procedimento comum que as viaturas se desloquem até o endereço dos investigados para buscar documentos pessoais, por ser uma exigência dos Distritos Policiais. Ao ser novamente questionado por esta magistrada, afirmou que alguns pertences no momento da abordagem não ficam com os abordados. Foram até a casa de SIDNEI para retirar o documento e encontraram as drogas. Se nada de ilícito tivesse sido visto, SIDNEI acompanharia eles para ingressar na casa, mas ingressaram sem ele apenas porque encontraram entorpecentes.

A testemunha Diego Roberto de Sousa Pedro, policial militar, declarou que se encontrava em patrulhamento e o carro do acusado passou em contrafluxo em velocidade moderada e, apenas ao cruzar, puderam sentir um odor de maconha. Foram abordados e, realizada a busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, foi encontrado um tijolo de maconha na parte traseira, entre o carpete. Os acusados foram separados e, então, LUCAS teria declarado que SIDNEI seria o fornecedor da droga. SIDNEI teria confessado a propriedade e o fornecimento

da droga, bem como que nada havia em sua casa. SIDNEI portava uma carteira, mas não tinha documento de identificação. Foi pedido apoio de outra viatura e deslocaram-se até a residência de SIDNEI. A casa estava trancada. Eram duas casas, uma embaixo e outra em cima. A janela estava aberta e através dela era possível ver na cozinha balanças de precisão, sacos de eppendorf, outro tijolo de maconha. Retornaram com SIDNEI ao local e entraram. SIDNEI afirmou que não havia mais ninguém em casa e eximiu qualquer outra pessoa de responsabilidade. Diante do fato foi dada voz de prisão a SIDNEI. Ao ser questionado por esta magistrada, afirmou que fez as buscas pessoal e domiciliar. Não perderam os acusados de vista em nenhum momento. Sentiram um odor forte de maconha quando cruzaram com o carro dos acusados. No momento da abordagem, nenhum estava usando droga. Os acusados não aparentavam ter usado drogas. Ao ser questionado pelo Ministério Público, afirmou que abriram a porta da casa com a chave de SIDNEI. Uma viatura ficou com os acusados no local e ele e seu parceiro foram à casa de SIDNEI. Como a mãe de SIDNEI não estava em casa e eles viram as drogas através da janela, a outra equipe levou os acusados até o local e pegaram a chave de SIDNEI. Não arrombou a porta, porque havia grades nas janelas e na porta, então era mais simples levar os acusados até o local. Por receio de fuga, num primeiro momento, SIDNEI não foi levado até o local, chegando apenas posteriormente. Ao ser questionado pela Defesa, afirmou que, no momento da abordagem, SIDNEI não portava nenhum documento de identificação, mas possuía carteira do veículo e celular. Não acessou o celular de SIDNEI, que teria se negado a dar acesso a eles ao conteúdo. Foram tiradas fotos do local. Não foi feita uma revista na outra casa (de baixo) porque estava vazia e aparentemente não era habitada. Ao ser novamente questionado por esta magistrada, reiterou que não realizaram busca na outra residência. SIDNEI teria informado que morava com sua mãe, mas ela não estava no local. O imóvel era composto por cozinha, banheiro, sala e quarto. Não parecia que a mãe de SIDNEI morava no local, parecia que ele morava sozinho.

O acusado LUCAS, em interrogatório, declarou ter 24 anos e nunca ter sido preso. Conhece SIDNEI há cerca de 2 ou 3 anos. No dia do ocorrido, saiu com o carro para encontrar uma amiga por volta das 21 horas. Seu carro é velho e estava em estepe e, como conheceu SIDNEI em uma borracharia, foi encontrá-lo a pé para pedir auxílio. SIDNEI disse que tinha um estepe e o pôs no carro. No caminho, foram abordados. Os policiais pressionaram SIDNEI para ver o conteúdo do celular dele, acessaram as conversas e alegaram ter encontrado conversas comprometedoras. Foram levados até a casa, que ele não conhecia, pois conhecia SIDNEI apenas da borracharia. Não acompanhou o ingresso na casa. Afirmou que desconhecia o tijolo de maconha encontrado no veículo, e que a voz de prisão ocorreu em função das conversas comprometedoras constantes do celular de SIDNEI. O Ministério Público não fez perguntas. Ao ser questionado pela Defesa, afirmou que mora aluguel com sua irmã e trabalha como montador e soldador.

O acusado SIDNEI, em interrogatório, declarou ter sido preso anteriormente por outros fatos. Estava em liberdade há cerca de 3 anos. Afirmou que, durante a abordagem, foi separado de LUCAS após ter declarado que possuía antecedentes. Durante a busca veicular, nada foi encontrado. Um dos policiais lhe pressionou para ter acesso a seu celular, e por medo ele deixou. Viram uma conversa em um grupo sobre drogas, e então começaram a perguntar-lhe sobre sua participação, mas ele disse não saber. Os policiais foram à rua de sua casa. Entraram na casa de sua namorada, encontraram drogas e o prenderam. Não sabe informar como os policiais sabiam o endereço da casa de sua namorada. Afirmou residir na Rua Rio São Francisco, nº 338, na mesma rua de sua namorada, mas em outro número. Os policiais não foram à sua casa, e no momento sua mãe estava no local. Ao ser perguntado pela Defesa, afirmou que LUCAS não teve nenhuma participação em todo o contexto.

As partes apresentaram memoriais (págs. 335/350, 351/364, 365/397), mas, devido à menção de prova superveniente nos memoriais da acusação, o acusado SIDNEI foi reinterrogado (págs. 447/448).

Em seu reinterrogatório, SIDNEI declarou ser inocente. Afirmou que foi abordados pelos policiais após ter ido ajudar LUCAS com um problema no pneu do carro. Os policiais o separou de LUCAS após ter afirmado que tinha antecedentes. O veículo foi revistado e nada foi encontrado. Então, começaram a perguntar sobre onde teria uma biqueira ou armas na região. Os policiais pediram que ele arranjasse uma arma para eles e ameaçaram forjar uma acusação. Uma outra viatura foi chamada e ficou com eles no local, enquanto os policiais militares que realizaram a abordagem foram para outro local. Depois de um bom tempo, foram levados à rua onde ele mora, mostraram drogas e afirmaram que lhe pertenciam. Foi preso em flagrante. Afirmou que a namorada mencionada no interrogatório anterior não existe, que seu relato sobre ela ocorreu porque ficou com medo porque estava sendo ameaçado por policiais e receio de prejudicar LUCAS. No dia da audiência anterior, policiais foram à residência de sua mãe e ameaçaram prejudicá-lo. O Ministério Público não fez perguntas. Ao ser questionado pela Defesa, afirmou residir na Rua São Francisco, nº 338. Desconhece Amanda. É borracheiro e trabalha no mesmo local em reside. Estava em liberdade há mais de 2 anos. No chaveiro do seu carro não havia chaves de outro endereço que não fosse o seu. No dia dos fatos, estava com seus documentos pessoais de identificação, inclusive habilitação digital.

Enfim, o Ministério Público e SIDNEI aditaram os memoriais (págs. 417/446 e 445/446).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é improcedente.

Em relação à imputação de tráfico ilícito de drogas formulada contra LUCAS ALEKSANDER DE SOUZA MARQUES e à imputação de associação para o tráfico formulada contra ambos os acusados, o próprio Ministério Público manifestou-se pela absolvição, o que equivale ao não exercício da pretensão acusatória e, consequentemente, implica absolvição, sob pena de exercício do poder punitivo sem provocação e violação ao princípio da correlação.

Ainda que assim não fosse, deve-se registrar que não foi produzida qualquer prova de que LUCAS concorreu para a infração penal imputada. Com efeito, o veículo em que teria sido encontrado um tijolo de maconha pertence a SIDNEI, e ambos os acusados, em seus interrogatórios, declararam que LUCAS estava no veículo porque SIDNEI, que trabalha em uma borracharia, estava lhe auxiliando a resolver um problema com o estepe de seu próprio carro. Ademais, os fatos posteriores – encontro de drogas em residência – dizem respeito unicamente a SIDNEI. Dessa forma, não havendo nenhum indício de que LUCAS tinha conhecimento a respeito dos entorpecentes, impõe-se sua absolvição em relação a ambas as imputações e, consequentemente, a absolvição de SIDNEI em relação à imputação de associação para o tráfico..

No que diz respeito à imputação de tráfico ilícito de drogas formulada contra SIDNEI PEREIRA GOMES, não há prova suficiente para condenação.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 13/14), pelos laudo de constatação provisória (págs. 63/67) e pelos laudos toxicológicos definitivos (págs. 293/294, 295/296 e 297/300), a prova coletada durante a fase de instrução não é suficiente para demonstrar o vínculo do acusado com os entorpecentes apreendidos.

As testemunhas declararam que encontraram um tijolo de maconha no veículo de SIDNEI e, pelo fato de ele não possuir documento de identificação, foram até sua

residência para buscar o documento em questão, por se tratar de uma exigência comum nos Distritos Policiais.

Por outro lado, ao serem interrogados, ambos os acusados declararam que nada de ilícito foi encontrado no veículo, e que os policiais foram à suposta residência de SIDNEI após encontrar "conversas comprometedoras" no celular dele, às quais tiveram acesso após pressioná-lo.

A análise minuciosa da prova oral dá relevo à versão dos acusados, a qual evidencia a fragilidade da versão das testemunhas.

Com efeito, as testemunhas não souberam explicar de forma clara o motivo pelo qual foram à Rua São Francisco, nº 475. Ambas afirmaram que foram até o local para buscar um documento de identificação de SIDNEI, mas este afirmou em seu interrogatório que o tinha no momento da abordagem.

Ademais, não é crível que, logo após uma apreensão de um tijolo de maconha, os policiais tenham deixado o local para buscar um documento pessoal de um dos abordados, sobretudo sem sua companhia. Se os policiais tivessem encontrado entorpecentes no veículo tal como alegaram, deveriam ter prontamente conduzido os acusados à presença da autoridade policial para lavratura do auto de prisão em flagrante. Dessa maneira, mesmo após a produção da prova oral, permanece obscuro o motivo pelo qual os policiais dirigiram-se à Rua Rio São Francisco, nº 475, onde encontraram os demais entorpecentes.

Destaque-se que o acusado SIDNEI juntou comprovante de residência referente a dezembro de 2021 (pág. 237), o qual registra que ele reside na Rua Rio São Francisco, nº 338, de modo que não há qualquer elemento de prova que evidencie seu vínculo com as drogas apreendidas no imóvel situado no nº 475 da mesma rua.

Não obstante o Ministério Público alegue ter juntado aos autos um vídeo em que uma mulher, que hoje seria inquilina da residência onde as drogas foram encontradas, teria dito que paga alugueres para o acusado e para a mãe dele (pág. 439), registro que não é possível extrair tal afirmação do vídeo em questão, pois se trata apenas de um trecho da conversa mantida entre os policiais militares e ela, o que inviabilizar sua valoração, mormente porque o vídeo inicia-se no decorrer de tal conversa, inviabilizando a compreensão do contexto das perguntas realizadas. Outrossim, não houve pedido de oitiva dessa pessoa como testemunha em juízo, a fim de fosse indagada, sob contraditório, a respeito dos fatos, o que fragiliza deveras seu valor probatório, principalmente porque dessa maneira não se permitiu à defesa o exercício da ampla defesa contra tal alegação – que resta afastada de qualquer maneira ante o comprovante de endereço juntado à página 237.

Ademais, não procede a alegação de que, ainda que nenhuma droga tivesse sido encontrada na casa do acusado SIDNEI, o encontro do tijolo de droga em seu carro seria suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Como dito, ambos os acusados negaram que elas tenham encontrado algo de ilícito na busca veicular. Outrossim, o auto de exibição e apreensão (págs. 13/14) menciona diversos tijolos de maconha, não individualizando qual teria sido encontrado no interior do veículo e quais foram encontrados na residência, o que enfraquece a versão das testemunhas de que houve apreensão de droga no veículo, sendo possível que todas as drogas tenham sido encontradas dentro da residência.

Com efeito, apenas o depoimento dos policiais não compõe acervo probatório robusto o suficiente para fundamentar condenação penal. Nesse cenário, ante a fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o estado de inocência.

No mérito, pois, a pretensão acusatória é improcedente. De qualquer forma, registro que, ainda que assim não fosse, seria hipótese de reconhecimento de nulidade das

provas produzidas, seja pela falta de justa causa para a realização de busca pessoal e veicular, seja pela acesso infundado ao conteúdo do telefone celular de SIDNEI.

É cediço que deve existir fundada suspeita que justifique a realização de busca pessoal e veicular, de modo que deve haver elementos concretos que impliquem suspeita de prática criminosa, não bastando a impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita dos indivíduos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal vulgarmente conhecida como dura, geral, revista, enquadro ou baculejo, além da intuição baseada no tirocínio policial:

a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se

tratar de conduta invasiva e constrangedora mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre , também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;

b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;

c) evitar a repetição ainda que nem sempre consciente de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.

7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.

8. Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra. Mais do que isso, os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).

9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais em verdadeiros "tribunais de rua" cotidianamente constroem os famigerados elementos suspeitos com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela.

10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal o que por certo não é verdade , as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno

lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de eficiência das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin.

12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da porta de entrada no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.

13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:

"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, conseqüentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal".

14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva, conformente a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.

(STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

No caso, as testemunhas declararam que abordaram os acusados porque sentiram odor de maconha ao cruzar com o veículo em que eles estavam, o que é inverossímil, já que não parece possível que os policiais, dentro da viatura, possam ter sentido o cheiro do interior de um outro veículo que passou no sentido contrário durante alguns segundos. De mais a mais, ambas as testemunhas afirmaram que, no momento da abordagem, nenhum dos acusados estava usando nem aparentava ter usado drogas, o que torna ainda menos provável que eles possam ter sentido o alegado odor de maconha apenas ao cruzar com o veículo dos acusados.

Por conseguinte, não demonstrada a fundada suspeita que pudesse justificar a abordagem, tem-se a invalidade de todos os elementos probatórios produzidos em consequência da busca pessoal e veicular.

Como se não bastasse, ambos os acusados declararam que os policiais acessaram o telefone celular de SIDNEI e o vincularam às drogas por terem encontrado "conversas comprometedoras" - cujo conteúdo não foi revelado. Dessa forma, ao que parece, a localização dos entorpecentes na Rua Rio São Francisco, nº 475, ocorreu a partir de um acesso indevido ao telefone celular de SIDNEI, o que constituiu prova ilícita.

É cediço que o acesso ao conteúdo de telefones celular depende de autorização judicial, sob pena de ilegalidade da prova. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACESSO A DADOS CONTIDOS NO CELULAR DO RÉU. RESERVA DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares - envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente.

2. Por ocasião da prisão em flagrante do paciente, o celular que portava foi apreendido, desbloqueado e nele verificada a existência de fotos que indicavam a possível prática do delito de tráfico de drogas. Ainda antes do acesso aos dados constantes do seu celular, os agentes estatais procederam à revista pessoal do acusado, não encontraram nada de ilícito em seu poder, tampouco no interior do seu veículo automotor.

3. Pelos documentos constantes dos autos, não se verifica, portanto, nenhum argumento ou situação que pudesse justificar a necessidade e a urgência, em caráter excepcional, de as autoridades policiais poderem acessar, de imediato (e, portanto, sem prévia autorização judicial), os dados armazenados no aparelho celular do paciente. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos, o que se depreende é que não haveria nenhum prejuízo às investigações se os policiais, após a apreensão do telefone celular, houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados.

4. Pela leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, é possível identificar, ainda, que não houve outros elementos informativos produzidos por fonte independente ou cuja descoberta fosse inevitável, porquanto o contexto da abordagem do ora paciente, aliado aos dados obtidos por meio do acesso ao seu celular e a posterior apreensão de drogas é que formaram a convicção do Parquet pelo oferecimento de denúncia pela possível prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e o posterior convencimento das instâncias ordinárias pela condenação do réu no tocante à prática do referido delito.

5. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de violação dos dados armazenados no aparelho celular do paciente - e, portanto, violação da sua intimidade e da sua vida privada -, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida (art. 5º, LVI, da Constituição da República) e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial.

6. Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise do pretendido reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

7. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso ao celular do paciente, bem como de todas as que delas decorreram e, consequentemente, absolvê-lo em relação à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Processo n. 0184051-80.2019.8.19.0001, da Vara Criminal da Comarca de Maricá - RJ)

(STJ, HC n. 609.221/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021)

De qualquer forma, deixo de decretar a nulidade do procedimento porque a solução do mérito é mais favorável aos acusados, já que as provas produzidas – ainda que nulas – não são suficientes para sua condenação.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e, consequentemente, ABSOLVO LUCAS ALEKSANDER DE SOUZA MARQUES, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e SIDNEI PEREIRA GOMES, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de SIDNEI PEREIRA GOMES.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Itaquaquetuba, 28 de julho de 2022.